

1501108-56.2020.8.26.0594

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: BEATRIZ TAVARES CAMARGO

Comarca: Pirajuí

Foro: Foro de Pirajuí

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 24/01/2022

... quanto ao cometimento dos crimes de tráfico de entorpecentes de de associação para o tráfico, além do crime de corrupção de menores.

As provas produzidas no curso da instrução criminal apontam para a parcial responsabilidade do denunciado

Em relação ao crime de tráfico de drogas, a materialidade do crime encontra-se devidamente comprovada diante do boletim de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pirajuí

Foro de Pirajuí

1ª Vara

Praça Dr. Pedro da Rocha Braga, 43, Pirajuí-SP - cep 16600-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1501108-56.2020.8.26.0594 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501108-56.2020.8.26.0594

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2283780/2020 - DEL.POL.PIRAJUI, 14677667 - DEL.POL.PIRAJUI, 756/20/111 - DEL.POL.PIRAJUI, 2283780 - DEL.POL.PIRAJUI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VINICIUS SILVA ZAMBOTI GOLIN

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BEATRIZ TAVARES CAMARGO

Vistos.

Trata-se de ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em desfavor de VINICIUS SILVA ZAMBOTI GOLIN, qualificado nos autos (fls. 11), como incurso no art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da lei n. 11.343/2006, e art. 244-B do Código Penal, porque em tese, no dia 13 de novembro de 2020, por volta das 19h30, na Avenida da Saudade nº 655, Parque Santa Brígida e, também, posteriormente, na Rua dos Beija Flores, nº 380, Bairro Pirajuí "C", na cidade e comarca de Pirajuí/SP, trazia consigo, para entrega ao consumo de terceiros, 05 (cinco) invólucros plásticos contendo maconha, com peso líquido de 13,48g, e 05 (cinco) pinos contendo cocaína, com peso líquido de 1,24 g, bem como, agindo em concurso e com unidade de

propósitos com seu irmão, o adolescente J.P.G.N, mantinham em depósito, para a mesma finalidade, 13 (treze) porções de maconha, com peso líquido de 21,02g, 01 (uma) porção de maconha em farelos, com peso líquido de 61,4g, e mais de 03 (três) invólucros contendo cocaína, com peso líquido de 0,78g, tratando-se de drogas destinadas ao consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Consta, que o denunciado, corrompeu o menor de 18 (dezoito) anos, J.P.G.N, para com ele praticar infração penal de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico de drogas.

A denúncia relata que, que em primeiro momento, policiais militares, durante patrulhamento, após receberem denúncias de que o denunciado estaria indo até o bairro Jardim dos Servidores para exercer a mercancia ilícita de entorpecentes, o abordaram na Avenida de Saudade e, em busca pessoal, localizaram, dentro de sua pochete, um pote de bala contendo 05 (cinco) porções de cocaína, a quantia de R\$ 97,00 (noventa e sete) reais em notas diversas e um aparelho celular da marca Samsung, modelo J2 prime. Em seguida, os policiais levaram o denunciado até sua residência, localizada na Rua dos Beija Flores, onde encontraram seu irmão, J.P.G.N, na calçada do imóvel, que ao avistá-los, tentou correr para o interior do imóvel. Em buscas pelo imóvel, apurou-se que o adolescente havia acabado de efetuar a venda de 02 (duas) porções de maconha para F.S.M, cliente dos irmãos. Ato contínuo, os policiais encontraram, sob um colchão do quarto do adolescente, um pote com maconha em farelos e, ao lado, ainda no chão do quarto, um canivete com resquícios de droga e mais de 17 (dezesete) sacolés plásticos, comumente utilizados para armazenar entorpecentes para posterior venda a terceiros. Logo acima o colchão, os policiais ainda encontraram a quantia de R\$ 439,00 (quatrocentos e trinta e nove reais) em cédulas e moedas diversas e, no guarda-roupas do mesmo cômodo, 124 (cento e vinte e quatro) "ependorfs" vazios, comumente utilizados para guardar cocaína. Posteriormente, dentro do armário de outro quarto do imóvel, foram encontrados um pote contendo mais de 13 (treze) invólucros plásticos com maconha, além de 03 (três) "ependorfs" contendo cocaína e um aparelho celular cor branco da marca Samsung, modelo Galaxy Ace, de propriedade do adolescente. Considerando a denuncia anônima recebida pela Polícia, a variedade da droga apreendida, já embalada e pronta para consumo, a mercancia realizada, os petrechos localizados, os valores apreendidos bem como as circunstâncias da apreensão, foi o denunciado preso em flagrante.

Oferecida a denúncia (fls. 188/192), e regularmente notificado (fl. 212), o réu apresentou defesa prévia (fls. 230/231), o que não impediu o recebimento da denúncia (fls. 261/263).

Designada audiência de instrução, debates e julgamento foram ouvidas quatro testemunhas arroladas em comum pelas partes, o adolescente arrolado pela defesa, sendo o réu interrogado ao final.

As partes apresentaram memoriais escritos (fls. 416/425 e 433/444).

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

Pesa sobre o réu, acusação quanto ao cometimento dos crimes de tráfico de entorpecentes e de associação para o tráfico, além do crime de corrupção de menores.

As provas produzidas no curso da instrução criminal apontam para a parcial responsabilidade do denunciado

Em relação ao crime de tráfico de drogas, a materialidade do crime encontra-se devidamente comprovada diante do boletim de ocorrência (fls. 14/18), pelo do auto de exibição e apreensão (fls. 19/21), pelo laudo de constatação provisória (fls. 45/48). Igualmente, a natureza entorpecente ilícita da substância apreendida foi regularmente ratificada pelo laudo toxicológico definitivo (fls. 243/246), que detectou a presença das substancias Tetrahydrocannabinol (THC) e cocaína.

A comprovação da natureza entorpecente da substância, imprescindível para o julgamento condenatório, é feita pela prova técnica, realizada por perito criminal, o que ocorreu no caso em tela.

A autoria está devidamente comprovada.

Ouvido na fase policial, a testemunha Isaque da Silva Bonifácio informou, que na data dos fatos estava em sua casa quando o indiciado Vinicius, lhe chamou para irem até o bairro do Jardim dos Servidores no "Delivery Furtado", que então por volta das 19h00min encontrou com Vinicius próximo à indústria "D7", localizada na Avenida Orestes Quêrcia desta cidade, sendo certo que, estavam indo até o citado bairro. Relata, que quando estavam chegando ao destino, foram abordados por Policiais Militares na Avenida da Saudade, ocasião em que foi submetido a busca pessoal, porém nada de ilícito foi encontrado em sua posse. Relata, ainda, que durante a abordagem, enquanto estava no chão da via pública, por ordem dos policiais, avistou o policial Siderval encontrar um pote de balas a aproximadamente 3 metros de distância, contendo porções de maconha e de cocaína. Aduz, que no trajeto até a delegacia Vinicius assumiu a autoria dos entorpecentes. Afirma, que não sabia que Vinicius trazia consigo os entorpecentes, bem como também não viu o mesmo jogando na via pública, pois ao avistar a viatura, apenas, ficou concentrado nos policiais. Por fim, relata, que já ouviu dizer que os irmãos Vinicius e José estavam praticando a traficância, mas também não sabia que eles armazenavam drogas na casa onde moravam.

Ouvido em Juízo como informante, ante a alegada amizade íntima com o réu, Isaque da Silva Bonifácio disse que estava junto com Vinicius. Iam comer um lanche e o depoente iria pagar. Disse que não tinham nada com eles. Os policiais efetuaram a abordagem e acharam a droga no chão. Foi o policial quem encontrou a droga. A droga estava há cerca de quinze metros deles. A droga não era deles. Nunca ouviu dizer que Vinicius e José Paulo praticavam tráfico.

Ouvido na fase policial, a testemunha Felipe Souza Moro, informa ser usuário de maconha e que na data dos fatos por volta das 18h30min foi até a casa de Vinicius e José a fim de comprar maconha. Chegando no local, apenas José encontrava-se no local, momento este que comprou dele 02 (duas) porções de entorpecente para seu consumo pessoal, sendo que pagou R\$ 10,00 (dez reais) cada. Relata, que aproximadamente 02 (duas) semanas vem comprando maconha de Vinicius e José e ficou sabendo que ambos estavam traficando, por informações que recebeu de pessoas do bairro onde mora. Aduz, que quando estava na casa de José, por lá chegaram policiais militares e abordaram José na calçada do imóvel, sendo que ele encontrava-se no sofá do imóvel. Informa, ainda que avistou os policiais encontrarem drogas como maconha e cocaína no interior daquela residência, onde após indagado sobre propriedade, relatou tais entorpecentes que lhe pertenciam, foi então que José assumiu a propriedade dos objetos. Por fim, conduzido até a delegacia, para corroborar com sua versão, autoriza juntamente com sua genitora que seja feita a análise do conteúdo de seu aparelho celular, para que seja localizada conversas indicativas de compra de drogas para seu consumo.

Em Juízo, ouvido na presença da genitora e devidamente compromissado, o adolescente Felipe Souza Moro disse que estava na casa de Vinicius buscar droga. Estava saindo, quando os policiais chegaram. Foi no local comprar droga. Seus amigos também compravam droga com Vinicius. Pagava cerca de R\$ 10,00 pela porção de maconha. Acha que os dois vendiam. Disse que nesse dia, comprou do irmão de Vinicius, conhecido como Neto. Pagou R\$ 20,00, pela maconha. Não sabe de outras pessoas que comprem com o réu e com o irmão. Costumava enviar mensagens pelo whatsapp para Vinicius, que consta como "Parceiro". Vinicius mora perto da casa do depoente, mas não sabe falar o número. Nesse dia, não teve contato com Vinicius. Comprou a droga de Neto. Já comprou drogas algumas vezes de Vinicius. No dia dos fatos, não viu os policiais pedirem autorização, já chegaram invadindo. Disse que há cerca de um mês um amigo compareceu em sua residência, dizendo que Vinicius e a testemunha Isaque estavam ameaçando o depoente de agressão. Ficou temeroso e postula medida cautelar para que Vinicius e Isaque não se aproximem dele.

O policial militar Enio Gustavo Clemente Garcia, em juízo, relatou que na data dos fatos, juntamente com o policial Siderval, quando receberam denúncias anônimas de que Vinicius estaria indo até o bairro do Jardim dos Servidores, neste município para fazer a venda ilícita de entorpecentes no estabelecimento conhecido como "Delivery Furtado", saíram em patrulhamento a fim de localiza-lo, sendo certo que,

próximo ao citado bairro, na Avenida da Saudade, lograram com êxito em encontra-lo caminhado em via pública juntamente com a testemunha Isaque. Aduz, que então foi procedido a busca pessoal em Vinicius e localizaram no interior de sua pochete, um celular marca Samsung, cinco porções de maconha, cinco porções de cocaína e a quantia de R\$ 97,00, em dinheiro. Deram voz de prisão em flagrante e dirigiram-se à casa de Vinicius. A mãe do réu também era conhecida e está presa por tráfico. Avistaram o irmão do réu, José Paulo, conversando com duas pessoas no portão. Essas pessoas fugiram correndo. José Paulo tentou fugir e foi abordado, mas não trazia nada com ele. Informa, que viram um rapaz saindo de dentro do quarto do adolescente José, sendo que, indagado sobre o que estava fazendo no imóvel. No interior do quarto, onde não havia cama, foi localizado embaixo do colchão que estava no chão, um pote contendo maconha em "farelos" já dichavada, porém, ainda não embaladas em porções, que ao lado do colchão, ainda no chão do quarto, foi localizado um canivete o qual possivelmente possa estar com resquícios de entorpecentes 17 sacolés plásticos, comumente utilizados para armazenar entorpecentes para posterior venda a terceiros. Dentro do guarda, do mesmo quarto, também foi localizado um pote de vidro com 123 eppendorfs vazios, os quais são comuns para armazenar cocaína para posterior comércio ilícito. No quarto de José havia R\$ 440 em dinheiro. O rapaz que saiu do quarto de José era Felipe Moro, que disse que não tinha relação com os fatos, dizendo para José contar a verdade. Na Delegacia, soube que Isaque disse que era usuário de drogas e sabia que José e Vinicius estavam vendendo drogas. Felipe disse que iria comprar drogas de José. Felipe autorizou a análise do seu aparelho celular. Vinicius já era conhecido nos meios policiais.

No mesmo sentido o depoimento do policial militar Eurides Siderval de Oliveira. Ouvido como informante, José Paulo Golin Neto, irmão do adolescente, disse que a droga e o dinheiro eram todos do depoente. Não sabe se já foi ouvido em Juízo em processo de apuração de ato infracional. Não permitiu que os policiais entrassem na casa. Os policiais chegaram agredindo o depoente. Toda a droga era sua, havia maconha, cocaína e "crack". Havia cerca de oitenta gramas e "umas paradas", cerca de catorze. Tinha 3 pinos de cocaína com o depoente. Não se recorda se o irmão usava pochete. Não sabe se foi localizada droga na pochete do irmão. O irmão havia comprado droga para Vinicius. Vinicius comprou droga do depoente, para o uso dele. No dia, havia entregue 5 pinos e 5 porções de maconha para o irmão usar. O irmão iria para a casa da namorada e iria usar. Estava em casa quando os policiais chegaram. No local, estava também Felipe. Havia um casal no portão. Conhece "Delivery Furtado", onde é vendida

Interrogado na fase inquisitorial, o acusado permaneceu em silêncio.

Em juízo, o réu Vinicius Silva Zamboti Golin disse que estava indo para a casa da namorada e pegou droga com o irmão, quando foi abordado pelos policiais. Os policiais encontraram 5 pinos de cocaína e 5 porções de maconha, além de R\$ 100,00. Os policiais levaram o depoente na casa onde foi encontrado o irmão. Falou para os policiais que não morava com o irmão e sim com a avó. Quando o irmão saiu da casa, e tentou entrar na casa. O policial Garcia pegou José pelo pescoço e levou para dentro da casa, agredindo ele. Após, algum tempo, trouxeram o irmão e colocaram ele na viatura policial. Usava maconha diariamente e cocaína aos finais de semana. Quando ia trabalhar, usava uma porção de maconha. Nos finais de semana, usava duas ou três porções. Pagava R\$ 10,00 na porção de maconha. Na época era servente de pedreiro e ganhava cerca de R\$ 1.200,00 por mês. Morava na casa de baixo, com a avó, no Jardim Aclimação. Ajudava comprando algumas coisas para ela, gastava cerca de R\$ 400,00, R\$ 500,00 por mês. Como trabalhava não usava muita droga, um ou dois. Trabalhava com o primo, chamado Leandro da Silva, no seu celular estava com o contato "Lê Primo". Morava com a avó no Jardim Aclimação, e o irmão ficava em outro Bairro, há cerca de quinze minutos de caminhada.

A despeito da versão exposta pelo acusado, o quadro probatório delineado acima permite a formação de juízo de convicção acerca da autoria e da materialidade do delito de tráfico descrito na denúncia, uma vez que os elementos probatórios coligidos aos autos evidenciam que o réu praticou a ação delitiva em comento.

Com efeito, os policiais militares ouvidos em juízo relataram, de modo uniforme,

que o acusado trazia consigo as substâncias entorpecentes indicadas na exordial acusatória.

Releva notar que o delito de tráfico de drogas, por consistir em crime de perigo abstrato, dispensa a demonstração propriamente dita da venda do entorpecente, sendo que, na espécie, houve demonstração suficiente de que a droga apreendida se destinava ao consumo de terceiros.

Ressalta-se, ademais, que, na situação dos autos, as palavras dos policiais apresentam confiabilidade, porquanto não foram trazidos dados verossímeis que pudessem desaboná-las e não se vislumbra que teriam qualquer motivo para prejudicar o réu.

Sobre o tema, inclusive, o C. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que: “2. Esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese” (AgRg no AREsp 1686847/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 10/08/2020).

E as palavras dos policiais foram corroboradas pela testemunha.

Observa-se que não houve a caracterização de excludentes de ilicitude ou de culpabilidade em favor do acusado e que este era imputável na data do delito e possuía consciência da ilicitude de sua conduta.

A prova produzida não deixa dúvidas de que o acusado praticou o tráfico de drogas, devendo responder penalmente pela conduta praticada.

Quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas, cuja finalidade específica dos agentes é o cometimento dos crimes previstos nos artigos 33 e 34 da Lei nº 11.343/06, o delito reclama uma associação dotada de estabilidade, que não se confunde com o concurso de agentes.

No caso em pauta, não há provas seguras de que o denunciado e o adolescente se reuniam, em caráter de estabilidade e permanência, de forma reiterada, para o cometimento do tráfico.

A eventual reunião de agentes caracteriza tão só o concurso de agentes, não havendo falar, dessa união, como tipo penal autônomo.

Neste sentido:

Apelação. Tráfico de drogas e associação. Insurgência defensiva. Alegada falta de provas. Falta de provas verificada apenas em relação ao delito de associação para o tráfico. Acusado abordado juntamente com uma adolescente, em conhecido ponto de venda de drogas. Entorpecentes apreendidos com a adolescente e todo o dinheiro apreendido em poder do apelante. Expediente comum, empregado por traficantes, buscando atribuir integral responsabilidade ao inimputável. Circunstâncias concretas que colocam em descrédito a versão defensiva. Mantida a condenação por tráfico. Art. 35 da Lei 11.343/06. Necessária distinção entre concurso de agentes e associação. Enquanto o primeiro se mostra ocasional e temporário, o segundo exige estabilidade e permanência. Fatos apurados que não demonstram o vínculo associativo duradouro. Existência de vínculo efêmero que não basta para a caracterização do delito de associação para o tráfico. Absolvição. Penas. Redução. Necessidade. Incidência do redutor previsto no art. 33, § 4º. Viabilidade. 25 gramas de cocaína e 0,6 grama de maconha. Redução em 2/3. Regime. STF. Declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/90. Avaliação do caso concreto. Pequena quantidade que autoriza o regime aberto. Penas alternativas.

Resolução 5/12 do Senado Federal. Suficiência das penas restritivas. Prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária. Apelos parcialmente providos. (TJSP; Apelação Criminal 0001550-50.2018.8.26.0535; Relator (a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Guarulhos - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 11/11/2015; Data de Registro: 08/09/2019).

No mesmo sentido, in verbis: "a jurisprudência deste Superior Tribunal firmou o entendimento de que, para a subsunção da conduta ao tipo previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006, é imprescindível a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa" (STJ - HC: 270837 SP 2013/0159054-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 19/03/2015, T6 - SEXTA TURMA, data de publicação: DJe 30/03/2015).

Note-se: a reunião de pessoas para a prática do crime de tráfico de drogas, por si só, não é suficiente para a condenação pretendida. Há necessidade inequívoca da estabilidade e permanência.

E, no caso dos autos, os elementos são suficientes para confirmar tão somente o concurso de agentes nos fatos ora apurados.

As provas dos autos não são suficientes para a conclusão, principalmente, da permanência da suposta associação, de modo que a absolvição é medida que se impõe, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

A imputação do crime de corrupção de menores, também deve ser afastada, pois haveria, no entender desta Magistrada, bis in idem, uma vez que a Lei de Drogas determina, em seu artigo 40, inciso VI, o aumento das penas dos crimes dos arts. 33 a 37 daquela Lei quando a conduta visar crianças ou adolescentes, por serem estas pessoas em formação física e psicológica.

Mencionado dispositivo legal prevê duas condutas, explicitadas pelos verbos "envolver" e "visar atingir" criança ou adolescente. Envolver significa atuar conjuntamente, utilizar ou contar com a participação do menor. Visar atingir é ter como objetivo, como meta final, destinar a droga ao menor.

E a prova produzida demonstrou satisfatoriamente a participação da adolescente, à época dos fatos menor de 18 anos, nas atividades ilícitas praticadas pelo réu.

Nesse sentido:

Apelação Criminal - Tráfico de entorpecentes praticado na companhia de adolescente (art. 33, "caput", cc. art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei nº 8.069/90), em concurso material - Recurso subsidiário visando a absolvição do sentenciado por insuficiência probatória e, subsidiariamente, o reconhecimento da absorção do delito de corrupção de menores pelo de tráfico de drogas - Autoria e materialidade bem demonstradas, com a venda de entorpecentes a um usuário tendo sido presenciada pelos policiais militares responsáveis pela prisão - Sentenciado que trazia consigo e guardava, na companhia do adolescente mencionado na denúncia, 54 porções de "cocaína" com peso líquido total de 59,23g - Reconhecimento da causa de aumento de pena do art. 40, VI, da Lei de Drogas e do delito previsto no ECA que caracteriza inegável "bis in idem" - Majorante prevista na Lei Antidrogas que é "norma especial" em relação à corrupção de menores, por se referir à prática, na companhia do(s) menor(es), de delito específico - Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça - Prisão cautelar do réu que fica mantida, nada obstante o decidido pelo STF nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade de nºs 43, 44 e 54, no dia 7.11.2019, ante a presença dos requisitos do art. 312 do Cód. de Processo Penal, nos termos da fundamentação contida no acórdão - Recurso parcialmente provido para absolver o sentenciado quanto à acusação de prática do delito do art. 244-B da Lei nº 8.069/90, com

fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, mantida a condenação pelo delito do art. 33, "caput", cc. art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06. (TJSP; Apelação Criminal 1500510-12.2019.8.26.0603; Relator (a): Otavio Rocha; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Araçatuba - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 25/05/2021; Data de Registro: 25/05/2021) - Destaquei.

Tráfico de entorpecentes. Policiais em patrulhamento de rotina que recebem informações de um transeunte de que dois indivíduos estavam escondendo entorpecentes em um matagal. E ao se deslocarem ao local, os milicianos observam, escondidos, o réu e o adolescente mexendo em um ponto específico. Policiais que aguardam os agentes deixarem o local e apreendem ali 26 tijolos de maconha e, posteriormente, efetuam diligência no imóvel do acusado e lá conseguem detê-lo e o jovem. Prova oral hábil. Palavras dos milicianos precisas e coerentes e que dão conta da responsabilidade do recorrente pelo comércio espúrio. Negativa isolada nos autos e que não convence. Condenação pelo tráfico de rigor. Corrupção de menor. Hipótese que, pela aplicação do princípio da especialidade, melhor comporta a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, já reconhecida. Caso em que a condenação pela prática do delito do artigo 244-B, do ECA, e o reconhecimento da causa de aumento mencionada implica "bis in idem". Associação para o tráfico. Inexistência de elementos que demonstrem o vínculo associativo entre o acusado e o adolescente. Indícios de que o réu e o jovem estavam associados que não constituem prova segura para indicar a vinculação psicológica ou o animus associativo entre eles. Hipótese que não comporta, portanto, a condenação do acusado pelo crime do artigo 35, da Lei nº 11.343/06. Penas do tráfico de entorpecentes que comportavam reparo. Pena-base que deveria ser majorada pela quantidade de droga apreendida, porém a questão não foi impugnada pela acusação. Inviabilidade da aplicação do redutor do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas. Substituição que não comporta acolhida. Regime fechado necessário. Apelo parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 0030107-89.2016.8.26.0576; Relator (a): Pinheiro Franco; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São José do Rio Preto - 4ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 07/06/2018; Data de Registro: 07/06/2018) - Destaquei.

Destarte, a pretensão procede parcialmente, em relação ao delito capitulado no artigo 33, da Lei nº 11.343/06.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase da dosimetria, a pena deverá ser fixada no mínimo legal, em razão da ausência de elementos que majorem as circunstâncias judiciais, fixo a pena em 5 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, não incidem agravantes. Constata-se a presença da atenuante da menoridade relativa, porquanto o acusado era menor de vinte e um anos na data do fato (CP, art. 65, I), mas, em atenção à súmula 231 do STJ, que veda a fixação da pena intermediária aquém do mínimo legal, mantenho a pena dimensionada na fase anterior.

Na terceira fase, presente a causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, elevo a pena em 1/6, o que perfaz 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Estão presentes os requisitos do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, de sorte que reduzo as penas de 2/3, resultando em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, pena esta que converto em definitiva pela ausência de outras circunstâncias modificadoras.

A recente orientação do Superior Tribunal de Justiça (em caráter de repercussão geral), forte em precedente do C. Supremo Tribunal Federal, é pelo afastamento da

hediondez no tráfico privilegiado. Este Juízo considera, assim, que não se justifica insistir, de forma indiscriminada, na aplicação da Lei 8.072/90 para sustentar regime gravoso ao réu que faz jus à aplicação da redutora do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas. Portanto, cumpre analisar o regime prisional cabível.

Diante do montante da pena aplicado e pela primariedade, o acusado deverá cumprir sua pena, inicialmente, em regime aberto.

Desta forma, substituo a reprimenda por duas restritivas de direito, quais sejam, prestação de serviços à comunidade pelo prazo integral da reprimenda, além de prestação pecuniária no importe de 1 (um) salário mínimo vigente à época do pagamento, valor este que será destinado à entidade assistencial a ser definida pelo Juízo da Execução.

Fixo o dia-multa no mínimo legal, à míngua de dados que permitam aferir eventual situação econômica mais abastada da ré.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal movida pelo Ministério Público, e o faço para CONDENAR a ré VINICIUS SILVA ZAMBOTI GOLIN, a pena de 1 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão, no regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços pelo tempo da condenação e ao pagamento de prestação pecuniária no valor de um salário mínimo, ambos à entidade a ser definida pelo juízo da execução penal, e a 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, no patamar mínimo legal de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, como incursa no art. 33, § 4º, c.c. art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/2006. ABSOLVO-O da imputação das práticas dos delitos previsto nos art.244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente e 35 da Lei nº 11.343/2006, com fulcro no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal

O réu poderá recorrer desta sentença em liberdade, se por outro motivo não estiver preso.

Nos termos do art. 72 da Lei nº 11.343/06, determino a destruição da amostra (se houver) de droga guardada para contraprova. Comunique-se à Autoridade Policial.

Decreto o perdimento da quantia monetária apreendida no momento da abordagem (fls. 19/21), em favor da União (artigo 63, da Lei 11.343/06).

Custas e despesas processuais na forma da lei.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o mais necessário, regularize-se e, nada havendo a ser tratado, archive-se estes autos com as cautelas de praxe.

P.I.C.

Pirajuí, 24 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA